

1500190-93.2021.8.26.0472

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VALDEMAR BRAGHETO JUNQUEIRA

Comarca: Porto Ferreira

Foro: Foro de Porto Ferreira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 24/02/2022

... o indivíduo que realizava o tráfico e fugiu como sendo o ora denunciado ISAC, vulgo "Isaquinho", pois já conhecido nos meios policiais por envolvimento criminoso quando adolescente (v.g. roubo, latrocínio e tráfico), bem como por já ter sido avistado no referido ponto de venda de drogas em outras ocasiões (cf. relatório de investigações de fls. 12/15, boletins de ocorrências ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porto Ferreira

Foro de Porto Ferreira

2ª Vara

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 525, . - Centro

CEP: 13660-017 - Porto Ferreira - SP

Telefone: (19) 3581-2201 - E-mail: portoferr2@tjsp.jus.br

1500190-93.2021.8.26.0472 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500190-93.2021.8.26.0472

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ISAC MATHEUS FERREIRA SOUZA

Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de ISAC MATHEUS FERREIRA SOUZA, já qualificado nos autos, como incurso no topo do artigo 33 da Lei 11.343/06 afirmando que em 15 de janeiro de 2021, por volta de 10h, na Estrada Municipal próxima à rua Cecílio Nicolau, Bairro Porto Belo, nesta cidade e comarca de Porto Ferreira, trazia consigo, no local conhecido como "Biqueira do Mandiocal", 20 porções de "cocaína com peso líquido de 8,58 gramas e 01 porção grande de "maconha" com peso líquido de 174,72 gramas. Segundo narrou denúncia, "na data dos fatos os policiais civis Brizano e Helder se dirigiram ao local conhecido como "Biqueira do Mandiocal" para apurar a informação recebida de que ali havia um indivíduo de blusa vermelha e bermuda escura realizando intenso tráfico de drogas. Os policiais, que estavam em viatura descaracterizada, realizaram então campana no local e puderam avistaram que um indivíduo com as citadas características estava em atividade típica da traficância, pois mantinha contato com os veículos que transitavam pela via, servindo-lhes entorpecentes e, em dado momento, agachou para esconder uma sacola numa moita. Diante da constatação do crime, os agentes se dirigiram para efetuar a prisão em flagrante do inculpado, mas este conseguiu se esquivar da ação e empreendeu fuga, correndo para o interior do bairro, onde pulou o muro de uma residência e se evadiu pelo telhado das casas vizinhas. Contudo, já no momento da ação os policiais conseguiram visualizar claramente o rosto e reconhecer o indivíduo que realizava o tráfico e fugiu como sendo o ora denunciado ISAC, vulgo "Isaquinho", pois já

conhecido nos meios policiais por envolvimento criminoso quando adolescente (v.g. roubo, latrocínio e tráfico), bem como por já ter sido avistado no referido ponto de venda de drogas em outras ocasiões (cf. relatório de investigações de fls. 12/15, boletins de ocorrências às fls. 16/34, depoimentos de fls. 36 e 38 e reconhecimento fotográfico de fls. 35 e 39). Na sequência, em busca pela moita onde o denunciado foi avistado escondendo a sacola, os policiais conseguiram localizá-la, sendo que nela havia 20 eppendorfs com "cocaína", uma porção grande de "maconha" com sinais de que estava sendo fracionada para venda, uma balança digital e a quantia de R\$ 125,00 em notas fracionadas, produto do tráfico. O local e circunstâncias em que se desenvolveu a ação, a denúncia recebida apontando a traficância e a movimentação típica avistada na campana, a quantidade e forma de acondicionamento das drogas, a apreensão de dinheiro em notas variadas, bem como a fuga do increpado ao notar a presença policial demonstram, com segurança, que ele trazia consigo e tinha em depósito os entorpecentes com a finalidade de tráfico." A denúncia foi recebida e o processo seguiu seu trâmite natural, com apresentação de defesa prévia, audiência de instrução e julgamento e alegações finais.

É o breve relatório.
Fundamento e decido.

O topo do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o comércio ilícito. O objeto material é a droga, o jurídico (finalidade da proteção penal) é a saúde pública.

No caso em exame, há prova da existência do crime e de sua autoria.

A existência do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/06), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 07/08), pelos laudos periciais (fls. 40/41 e 42/45) que resultaram positivos para as drogas encontradas e, sobretudo, pela prova oral colhida. A autoria também é certa.

A testemunha de acusação, o policial civil Brizano Aparecido da Silva, na fase policial, disse que "na manhã do dia 15 de janeiro do corrente ano aportou no setor de investigações denúncia anônima de que no bairro Porto Belo I, um indivíduo de blusa vermelha e bermuda de cor escura estava promovendo o tráfico de drogas na biqueira conhecida como "biqueira do mandiocal", que fica localizada as margens da Estrada Municipal, paralela a Rua Cecílio Nicolau, bairro Porto Belo I, nesta cidade; que o depoente da companhia do Escrivão de Polícia Helder se dirigiram até o local em uma viatura descaracterizada e observaram o citado indivíduo servindo drogas para os veículos que passavam na via; que em dado momento o depoente observou quando o indivíduo agachou-se para esconder a sacola de drogas que estava consigo em uma moita de capim. Diante disso, na companhia do colega Helder, saíram para efetuar a abordagem dando voz de prisão ao indivíduo, ocasião em que conseguiu esquivar-se da investida policial, correndo sentido interior do bairro, onde pulou o muro de uma residência e obteve acesso ao telhado das casas, não sendo possível sua detenção. Que o depoente conseguiu avistar claramente o rosto do indivíduo o qual é conhecido como "Izaquinho", indivíduo este que sempre é visto na citada "biqueira do mandiocal" e também conhecido em face ao envolvimento em várias ocorrências policiais; que após os fatos o depoente e seu colega, foram até o local onde o indivíduo havia ocultado a sacola com as drogas, obtendo êxito em localizá-la; em seu interior haviam: 20 porções de cocaína, uma porção maior de maconha a qual havia sinais de que estava sendo fracionada, uma balança digital, R\$125,00 (cento e vinte e cinco reais em dinheiro, sendo 1 nota de R\$ 50,00, 3 notas de R\$

20,00, 1 nota de R\$10,00 e 1 nota de R\$ 5,00). que na Delegacia, foi realizada a identificação completa da pessoa de "Izaquinho", identificado como Isac Matheus Ferreira Souza; que ao observar a fotografia de Isac Matheus Ferreira Souza, o reconheceu sem sombra de dúvidas como sendo a pessoa de "Izaquinho", citado no boletim de ocorrência que deu início a esse procedimento." Em juízo manteve sua versão. Reconheceu a pessoa acusada porque a viu de frente e muito de perto; a pessoa é acusada é conhecida dos meios policiais, inclusive pelo latrocínio de um vereador. Começou a trabalhar na comarca no início de 2019. Fatos se deram entre 8h e 10h. Estava junto com Hélder; pilotava a moto. O veículo é do estado, mas não tem GPS. Seu celular tem GPS. Fazem o controle da circulação do veículo abrindo o talão. Mas não conseguem fazer isso porque há uma pendência a respeito da incorporação deste bem ao patrimônio público. A diligência foi feita com ciência da autoridade policial, a qual designou seu companheiro de serviço. É investigador. Hélder é escrivão. Delegado era o Dr. Eduardo. O procedimento consiste em: ao receber uma denúncia passa ao delegado; este determina, por escrito (ordem de serviço) ou verbalmente, a ordem para execução de diligência. Outra viatura estava em outra ocorrência, mas diante da fuga saíam em apoio a esta equipe. Viu a motocicleta e um carro parando; como estavam numa moto, não havia como capturar a placa pela distância. A pessoa acusada, quando fugiu, estava havia a uma distância menor. Traficantes correm com a droga porque precisam pagar caso sejam capturados pela polícia. Não gravaram a abordagem porque estavam de moto.

A testemunha de acusação, o policial civil Hélder Augusto de Oliveira, na fase policial, disse que "na manhã do dia 15 de janeiro do corrente, na companhia do colega investigador Brizano, foram até o bairro Porto Belo, para fins de averiguação de uma denúncia anônima de que no citado bairro, um indivíduo de blusa vermelha e bermuda de cor escura estava promovendo o tráfico de drogas na biqueira conhecida como "biqueira do mandiocal"; que o depoente e seus colegas se dirigiram até o local em uma viatura descaracterizada e observaram o indivíduo citado na denúncia, servindo drogas para os veículos que passavam na via; que em dado momento foi observado quando o indivíduo agachouse para esconder a sacola de drogas que estava consigo em uma moita de capim. Diante disso, saíram para efetuar a abordagem dando voz de prisão ao indivíduo, ocasião em que este conseguiu esquivar-se da investida policial, correndo sentido interior do bairro, onde pulou o muro de uma residência obtendo acesso ao telhado das casas êxito na fuga. Que o depoente conseguiu avistar claramente o rosto do indivíduo, porém não o conhecia; que após os fatos o depoente e seu colega, foram até o local onde o indivíduo havia escondido a sacola com as drogas, obtendo êxito em localizá-la; em seu interior haviam: 20 porções de cocaína, uma porção maior de maconha a qual havia sinais de que estava sendo fracionada, uma balança digital, R\$125,00 (cento e vinte e cinco reais em dinheiro, sendo 1 nota de R\$ 50,00, 3 notas de R\$ 20,00, 1 nota de R\$10,00 e 1 nota de R\$ 5,00). que na Delegacia, foi realizada a identificação completa da pessoa de "Izaquinho", reconhecido inicialmente por seu colega, sendo ele identificado como Isac Matheus Ferreira Souza; que ao observar a fotografia de Isac Matheus Ferreira Souza, o reconheceu sem sombra de dúvidas como sendo a pessoa de "Izaquinho", citado no boletim de ocorrência que deu início a esse procedimento." Em juízo manteve sua versão. Disse que havia outras pessoas no local, mas reconheceu a pessoa acusada.

ISAC MATHEUS FERREIRA SOUZA, disse que é inocente. Não estava no dia naquele local. Não pode dizer onde estava, pois faz muito tempo e não se lembra bem, mas pode garantir que não estava naquele local. Isso porque nessa época estava trabalhando com seu primo de pintor. Há motivo para falsa incriminação: os policiais ficam atrás dele por conta do que já fez na adolescência. Mas afirmou que depois que saiu da Fundação CASA não tomou nenhum "enquadro". Entre a data dos fatos e a prisão não recebeu nenhuma abordagem policial. Às vezes vai naquele bairro ver sua tia doente. Entre o bairro onde mora e o local dos fatos há uma distância de 2km. Não foi ouvido pela autoridade policial.

Embora tenha negado os fatos, a versão dada pelo acusado de que não era a pessoa identificada não encontra respaldo nas demais provas e elementos de convicção,

ficando isolada (não trouxe qualquer elemento que corroborasse suas alegações). Até porque foi incapaz de infirmar o restante do contexto probatório, que lhe é contrário, sequer apontando um motivo idôneo a motivar a prova oral colhida robusta trazida pela acusação ou explicar eventuais equívocos nas provas materiais.

O apontamento de falsa incriminação com base em perseguição perde força na medida que a própria pessoa acusada reconheceu que não sofreu qualquer abordagem invasiva por parte das forças policiais.

Por outro lado, os depoimentos das testemunhas foram uniformes e coerentes, amparados por tudo o mais que foi colhido antes e durante este processo, atestando a existência do crime e a sua autoria conforme a denúncia oferecida pelo Ministério Público.

O tipo subjetivo é inferido pelo local dos fatos (intenso ponto de tráfico) e pela quantidade de drogas.

Com a devida vênia à defesa, portanto, configurado, assim, o delito de tráfico de drogas, cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa".

Passo a dosar as penas.

Primeira etapa. Só há contra o réu uma circunstância não preponderante, a qual será sopesada, conforme orientação jurisprudencial, na terceira fase. Pena-base no mínimo legal.

Segunda etapa. Presente a atenuante da menoridade relativa (inciso II do art. 65 do Código Penal).

Impossível, nesta fase, reduzir a pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ e Tema 158 da Repercussão Geral do STF – RE 597270 QO-RG/RS, rel. Min. Cezar Peluso, julgado em 26/03/2009, DJe 05/06/2009).

Terceira etapa. Conforme entendimento consolidado do STJ, a quantidade de drogas, de forma isolada, não pode afastar a figura privilegiada do tráfico.

Com grifos nossos:

PENAL, PROCESSO PENAL E CONSTITUCIONAL. DOSIMETRIA DE PENA. PECULIARIDADES DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE A SER OBSERVADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO TOLERÂNCIA NA ORDEM CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO PARA RESTAURAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.

1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador.

2. Em regra, abre-se espaço, em sua primeira fase, à atuação da discricionariedade ampla do julgador para identificação dos mais variados aspectos que cercam a prática delituosa; os elementos negativos devem ser identificados e calibrados, provocando a elevação da pena mínima dentro do intervalo legal, com motivação a ser necessariamente guiada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Na estrutura delineada pelo legislador, somente são utilizados para a fixação da pena-base elementos pertencentes a seus vetores genéricos que não tenham sido previstos, de maneira específica, para utilização nas etapas posteriores. Trata-se da aplicação do princípio da especialidade, que impede a ocorrência de bis in idem, intolerável na ordem constitucional brasileira.

4. O tratamento legal conferido ao tráfico de drogas traz, no entanto, peculiaridades a serem observadas nas condenações respectivas; a natureza desse crime de perigo abstrato, que tutela o bem jurídico saúde pública, fez com que o legislador elegeisse dois elementos específicos necessariamente presentes no quadro jurídico-probatório que cerca aquela prática delituosa, a saber, a natureza e a quantidade das drogas para utilização obrigatória na primeira fase da dosimetria.

5. Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise desses

elementos para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual.

6. O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual.

7. A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712).

8. A utilização supletiva desses elementos para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa.

9. Na modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, podem ser utilizadas circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não utilizadas de maneira expressa na fixação da pena-base.

10. Recurso provido para restabelecimento da sentença.

REsp 1887511/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021.

A acusação, entretanto, apontou a existência de atos infracionais como prova da dedicação às atividades criminosas. A posição pacificada pelo STJ, que até admite o uso desses elementos para afastar o redutor (EREsp 1916596/SP, rel. para o acórdão Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 08/09/2021, DJe 04/10/2021), é pela exigência de motivação concreta.

No caso, nota-se não só um vasto rol de atos infracionais, mas como a gravidade deles (hediondos ou equiparados a tal). Com destaque para um latrocínio contra um vereador da cidade.

Ademais, a prisão foi precedida de investigação por parte dos policiais civis apontou para a realização do tráfico na "biqueira do mandiocal", local no qual há inúmeras ocorrências relacionadas ao comércio espúrio, fato que indica a dedicação do réu às atividades criminosas, principalmente porque os agentes de segurança pública disseram notar o réu com frequência naquele ponto.

Considerando o total de pena imposto e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial deverá ser, conforme orientação jurisprudencial, o fechado.

O regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena de 5 anos de reclusão, em razão da aferição negativa de circunstância judicial, que justificou o aumento da pena-base, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

STJ, HC 444200/RJ, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 14/08/2018, DJe 23/08/2018.

O montante da pena privativa de liberdade impede a substituição por penas restritivas de outros direitos, bem como a sua suspensão condicional.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR ISAC MATHEUS FERREIRA SOUZA à pena de reclusão, pelo prazo de cinco anos, em regime inicial fechado, bem como a 500 dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em virtude da conduta típica descrita no topo do artigo 33

da Lei 11.343/06.

Confirmando-se agora em cognição plena a existência do crime e sua autoria e não se apurando nada que infirme a periculosidade concreta do acusado, as razões de sua prisão cautelar estão mantidas.

3. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

(...)

5. A técnica de motivação per relationem revela-se legítima se a sentença condenatória faz remissão às circunstâncias ensejadoras da decretação de prisão preventiva no início do feito, tendo em vista que elas permanecem incólumes.

STJ, Sexta Turma, RHC 86.384/SP, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017.

Aliás, a custódia cautelar em casos análogos tem sido mantida pelos tribunais superiores:

3. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado.

4. Na espécie, a custódia cautelar foi mantida para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos, caracterizada pela quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas em poder dos agentes - cocaína (13 pinos), crack (53 pedras) e maconha (72 trouxinhas).

5. Ordem denegada.

STJ, Sexta Turma, HC 375559/SP, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 22/11/2016, DJe 07/12/2016.

O tempo de prisão preventiva não autoriza, por hora, qualquer mudança em seu regime prisional.

Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se a assistência judiciária gratuita, uma vez que lhe foi nomeado advogado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Expeçam-se as certidões de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos institutos de identificação criminal, ao cartório distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

Declaro o perdimento de todos os valores e bens apreendidos em favor da União Federal, ainda que não se tenha comprovado a sua habitualidade na prática do tráfico, conforme artigo 63 da Lei n. 11.343/06, que regulamenta o parágrafo único do art. 243 da Constituição, e sua interpretação dada pelo pleno do STF. Todavia, por serem inservíveis e antieconômicos para a SENAD, determino a destruição ou doação dos seguintes bens: 01 (uma) balança digital.

Nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06 e Comunicado CG 2225/18, determino a destruição de eventuais amostras de entorpecentes guardadas para contraprova.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Porto Ferreira, 24 de fevereiro de 2022.

Valdemar Bragheto Junqueira - Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA